

1501855-64.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 3ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THALES GOMES DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS DADALTO SAHÃO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra THALES GOMES DOS SANTOS (fls. 176/178), qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

3ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes - SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501855-64.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501855-64.2021.8.26.0628

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THALES GOMES DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS DADALTO SAHÃO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra THALES GOMES DOS SANTOS (fls. 176/178), qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pela suposta prática do seguinte fato delituoso:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 23 de setembro de 2021,

por volta das 12h00, na Rua Wladimir Herzog, altura nº 100, Viela, Pirajussara, nesta cidade e Comarca de Embu das Artes, THALES GOMES DOS SANTOS, qualificado a fls. 04, tinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 808g de maconha, acondicionada em 126 porções, 120g de cocaína em pó, acondicionada em 78 microtubos, e 90g de "Crack", substância derivada da cocaína, divididas em 74 porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 14/16. (fl. 176). A denúncia foi recebida em 06.10.2021 (fls. 179/180).

Regularmente notificado, o denunciado apresentou defesa prévia, por intermédio de defensor constituído, refutando o teor da denúncia e arrolando testemunhas (fls. 181/189).

Em não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento para a presente data (fl. 339).

Na data aprazada, colhidos os depoimentos das testemunhas, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais oralmente (termo e mídia audiovisual da segunda audiência).

É o relatório. Fundamento e decido.

Não há que se cogitar de inépcia da denúncia. O representante do Parquet que a subscreveu noticiou, pormenorizadamente, naquela peça exordial acusatória, a imputação lançada contra o denunciado, sua conduta e a respectiva capitulação delitiva, em observância ao disposto do art. 41 do CPP. Ao contrário do alegado, eventual equívoco na quantificação dos entorpecentes supostamente armazenados pelo agente compreende mera irregularidade, não tendo obstado o exercício do direito de defesa no transcurso da persecução penal; na ausência de prejuízo, não há que se falar em nulidade (art. 563 do CPP).

Tampouco vinga a preliminar de quebra da cadeia de custódia das drogas apreendidas, por pretensão defeito na confecção do laudo definitivo de exame químico-toxicológico. Para além de não vislumbrar qualquer ilegalidade ou inconsistência no laudo de químico-toxicológico capaz de macular a prova técnica produzida, ainda que faltasse a juntada desse exame, não haveria óbice ao julgamento do mérito do feito, na medida em que o laudo de constatação foi devidamente assinado por perito, e a materialidade do fato é inconteste. Nessa direção aponta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PRELIMINAR E OUTROS MEIOS DE PROVA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO.

1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, deve ser conhecido o recurso.

2. Tendo sido juntado laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína, e estando corroborado com as demais provas dos autos, a materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada, sendo prescindível a existência de laudo toxicológico definitivo.

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial.

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento.

(AgRg no AREsp 1578818/MG, Sexta Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 10.12.2019, DJe 13.12.2019); e

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, OS FUNDAMENTOS DO DECISUM COMBATIDO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE NA CONDENAÇÃO COM SUPORTE NA AUSÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MERA IRREGULARIDADE. LAUDO PRELIMINAR ATESTANDO A QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO.

SUFICIÊNCIA PARA AFERIÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE.

1. O agravo em recurso especial não foi conhecido em razão do óbice constante da Súmula 83/STJ.
 2. A insurgência não merece prosperar, haja vista o agravante não ter atacado de forma específica os fundamentos da decisão agravada, incidindo, no caso, a Súmula 182/STJ.
 3. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgRg no AREsp n.1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018).
 4. Nos termos da Súmula 182 desta Corte, é manifestamente inadmissível o agravo regimental que não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão confrontada (AgRg no AREsp n. 1.056.485/ES, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 2/4/2018).
 5. Existem precedentes no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a juntada de laudo prévio de constatação da substância, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido, tem o condão de firmar a materialidade do delito de tráfico de drogas.
 6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, entendeu que o laudo de constatação provisório que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida supre a ausência de laudo definitivo (ut, RESp 1727453/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 15/6/2018) (AgRg no RESp n. 1.542.110/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/3/2019).
 7. Além da existência de outros indícios que caminham no sentido de corroborar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas imposto ao recorrido, destaca-se que o auto de constatação preliminar, colacionado às fls. 25/27, contém a descrição da quantidade e da qualidade da substância entorpecente apreendida.
 8. Tendo sido juntado laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como maconha e crack, a materialidade do ato infracional equiparado ao tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada, sendo prescindível a existência de laudo toxicológico definitivo, se corroborada com as demais provas dos autos, como na espécie. [...] Não há que se falar em nulidade do laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, por ausência de informações sobre a qualificação do perito, uma vez que o perito oficial está devidamente identificado com seu nome, consoante portaria de nomeação de peritos e termo de compromisso (HC n. 464.142/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 6/12/2018).
 9. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1679885/MG, Sexta Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06.04.2021, DJe 12.04.2021).
- Nesse sentido:
- Nulidade - Quebra da cadeia de custódia não verificada - Ausência de prejuízo para a produção da prova técnica -Preliminar rejeitada.
- Tráfico de drogas - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Absolvição por ausência de provas - Impossibilidade - Condenação mantida - Recurso improvido.
- Pena-base acima do mínimo legal - Reincidência e maus antecedentes - Ausência de "bis in idem" quando utilizadas condenações diversas para exasperar a reprimenda na primeira e na segunda etapa - Recurso improvido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1516345-64.2020.8.26.0228, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Klaus Marouelli Arroyo, j. 26.04.2022).
- Afastadas as prefaciais, passo à análise do mérito da demanda.
- A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 1), no boletim de ocorrência (fls. 8/10), no auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), no laudo de constatação das substâncias apreendidas (fls. 14/16) e no laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 205/207). Depreende-se de tais elementos cognitivos que foram apreendidas em poder do acusado 353,2 gramas de maconha (acondicionadas em 126 porções), 51,4 gramas de cocaína (acondicionadas em 78 microtubos) e 18,1 gramas de crack (acondicionadas em 74 porções), além de R\$ 55,00 em espécie. O exame químico-toxicológico atesta que as substâncias entorpecentes

apreendidas são causadoras de dependência física e psíquica e de uso proibido em todo o território nacional, conforme a Portaria nº 344/1998 da Secretária da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

A autoria também é certa, exsurgindo da prova vocal produzida nos autos, sob o crivo do contraditório.

Tanto em solo policial (fls. 2 e 3), quanto em juízo (mídia audiovisual da segunda audiência), os policiais civis que realizaram a diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado, Guilherme Kazuo Sugawara (condutor) e Leandro Ferreira dos Santos, ouvidos na condição de testemunhas, apresentaram versões harmônicas, dando conta da ocorrência dos fatos narrados na peça acusatória. Narraram, em uníssono, que: receberam denúncia de que havia indivíduos praticando o tráfico de drogas, tendo diligenciado até as imediações do local dos fatos, em veículo descaracterizado; após breve campana, verificaram uma aglomeração suspeita de indivíduos próximos a uma sacola; no momento em que iniciaram a abordagem, os indivíduos notaram a aproximação dos policiais e empreenderam fuga, mas lograram êxito em deter um daqueles, identificado como o acusado, que ostentava as características físicas e de vestimentas descritas na notícia repassada; na sacola que estava próxima da aglomeração, a cerca de três metros, localizaram as porções de cocaína, maconha e crack discriminadas na exordial acusatória, afora o dinheiro em espécie; indagado informalmente sobre os fatos, o réu ficou-se silente.

Silente na senda judicial (fl. 6), em juízo o réu negou a prática delitiva, alegando, em suma, que estava apenas de passagem pelo local e que as drogas não lhe pertenciam, tendo sido o flagrante forjado pelos policiais civis.

A versão apresentada pelo acusado, afora ser fruto do exercício do direito à autodefesa, inclusive de mentir, restou isolada no conjunto probatório, não se afigurando verossímil, muito menos resistindo ao confronto com os demais meios de prova carreados aos autos, convincentes e bastantes para lastrear o édito condenatório.

A par de os depoimentos dos policiais civis serem seguros, claros e congruentes, a jurisprudência dos tribunais superiores de há muito consolidou o entendimento de que a palavra deles tem eficácia probatória, desde que não se evidencie o deliberado intuito de prejudicar o réu – em razão, por exemplo, de alguma inimizade ou perseguição pessoal. Sobretudo em casos como o presente, envolvendo tráfico de drogas, há de se atribuir especial realce aos depoimentos dos policiais que efetuaram a diligência, que tem o dever legal de preservar a ordem pública. Não se patenteou a intenção dos agentes policiais em incriminar gratuitamente o acusado e/ou mero interesse em justificar a abordagem e a prisão, e as versões fáticas não se mostraram facciosas, não subsistindo motivo para desmerecê-las.

Admitido o valor probante dos testemunhos, não vinga a tese da absolvição por falta de provas da autoria. Embora a defesa meneie a tese de que as drogas para acondicionamento foram “forjadas” pelos policiais civis, tal argumentação não é minimamente crível. Foi apreendida quantidade razoável das substâncias entorpecentes, de naturezas diversas – sendo que um flagrante por tráfico poderia ser “fabricado” com uma quantidade consideravelmente inferior, caso fosse esse o intento dos agentes públicos -, e a origem lícita e as razões para o armazenamento dos estupefacientes encontrados na bolsa não foram comprovadas nos autos, ônus que incumbia à defesa (art. 156 do CPP), de sorte que não vinga a absolvição por falta de provas.

Ressalto, em remate, não ser necessária a constatação da venda e distribuição propriamente dita da droga para que o agente seja responsabilizado criminalmente, bastando à configuração do tipo misto alternativo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 que ele traga consigo ou guarde narcóticos destinados ao comércio ilegal. Na lição de LUIZ FLÁVIO GOMES:

Consuma-se o crime com a prática de qualquer um dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo ato de tráfico. Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (por exemplo, expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa. (Lei de Drogas comentada artigo por artigo: Lei 11.343/2006, de 23.08.2006, 3. ed. rev.,

atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pp. 185/186). Tampouco há de ser aplicada a minorante do tráfico privilegiado, estampada no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Mencionada figura dita a redução da pena de um sexto a dois terços, desde que o agente, cumulativamente, seja (i) primário (não reincidente); (ii) de bons antecedentes (não ostente condenação criminal anterior transitada em julgado); (iii) não se dedique às atividades criminosas (desenvolva algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada ao crime, sendo o crime de tráfico a ele imputado no processo um evento isolado em sua vida); e (iv) não integre organização criminosa (associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013).

No que diz especificamente com o requisito negativo da não dedicação a atividades criminosas, CLEBER MASSON pontua que "(...) a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso pode (e deve) ser utilizada pelo magistrado como circunstância apta a afastar a figura privilegiada, pelo fato de indicar a dedicação do agente a atividades criminosas, nada obstante seja vedado utilizar tais fatores como circunstância judicial desfavorável, na dosimetria da pena-base, uma vez que não caracterizam maus antecedentes." (Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019). Comungando do mesmo entendimento, RENATO BRASILEIRO DE LIMA ressalva que, "conquanto não seja possível a utilização de inquéritos policiais e processos penais em curso para se concluir que o acusado tenha maus antecedentes, admite-se a utilização desse critério para formar a convicção de que o réu se dedique a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Não se trata de avaliação de inquéritos ou processos penais para agravar a situação do réu condenado por tráfico de drogas, mas sim uma forma de se afastar um benefício legal, porquanto existentes elementos concretos para concluir que ele se dedique a atividades criminosas, sendo inquestionável que, em determinadas situações, a existência de investigações e/ou ações penais em andamento possam ser elementos aptos para formação da convicção do magistrado. Ademais, como os princípios constitucionais devem ser interpretados de forma harmônica, não merece ser interpretado de forma absoluta o princípio da inocência, de modo a impedir que a existência de inquéritos ou ações penais impeçam a interpretação em cada caso para mensurar a dedicação do réu em atividade criminosa. Assim não o fazendo, conceder o benefício do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 para aquele que responde a inúmeros processos penais ou seja investigado é equipará-lo com quem numa única ocasião na vida se envolveu com as drogas, situação que ofende o princípio também previsto na Constituição Federal de individualização da pena." (Legislação criminal especial comentada: volume único. 9. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JusPODIVM, 2021, p. 1.085). (Negritei).

Esse entendimento doutrinário tem ressonância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no julgamento do EResp 1.431.091/SP em 14.12.2016, pela 3ª Seção, sob a relatoria do eminente Ministro Felix Fischer, ocasião em que se obtemperou que "o crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, LXII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação da proteção deficiente".

A partir desse precedente, a Corte Superior de Justiça vem majoritariamente reafirmando, por meio de suas duas turmas com competência criminal, o posicionamento no sentido de que a existência de persecuções penais pendentes de definitividade é apta a afastar o redutor em análise quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva (no ponto: HC 450.153/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.08.2018; AgRg no AREsp 1.251.694/SP, 5ª Turma, rel. Min. Felix Fischer, j. 05.08.2018; HC 442.254/RS, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da

Fonseca, j. 03.05.2018; AgRg no AREsp 999.769/RS, 6ª Turma, rel. Min. Nélson F. de Souza, j. 06.11.2017; e AgRg no REsp 1.678.417/GO, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Ribeiro, j. 17.04.2018).

Essa compreensão também prepondera no âmbito das Câmaras de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (confirmam-se, por todas: Apelação Criminal nº 1501744-74.2018.8.26.0567, 7ª Câmara, rel. Des. Otávio Rocha, j. 13.06.2021; Apelação Criminal nº 0000118-89.2018.8.26.0019, 15ª Câmara, rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, j. 02.06.2021; Apelação Criminal nº 1527069-30.2020.8.26.0228, 2ª Câmara, rel. Des. André Carvalho e Silva de Almeida, j. 24.05.2021; Apelação Criminal nº 1510569-83.2020.8.26.0228, 12ª Câmara, rel. Des. Vico Mañas, j. 12.05.2021; e Apelação Criminal nº 1502243-35.2019.8.26.0628, 1ª Câmara, rel. Des. Diniz Fernando, j. 19.04.2021).

Na espécie, consta da certidão de fls. 32/34 e do sistema e-SAJ que está em trâmite outra persecução penal em desfavor do acusado por tráfico de drogas (autos nº 1501855-64.2021.8.26.0628). Apesar de ser tecnicamente primário, o réu já teve outro envolvimento criminal, pela suposta prática de delito idêntico, tendo sido preso em flagrante pelo delito ora sob análise logo após ser beneficiado com a liberdade provisória nestes autos. A reiteração de condutas delituosas, ainda que não decorra de condenações transitadas em julgado, demonstra a dedicação a atividades criminosas, inviabilizando a aplicação da causa de diminuição de pena em foco.

Logo, ausentes excludentes de ilicitude, dirimentes de culpabilidade e/ou causas de extinção da punibilidade, a responsabilização criminal do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar a pena aplicável, em atenção ao sistema trifásico perfilhado pelo CP (arts. 59 e 68).

Na primeira fase, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, as circunstâncias estatuídas pelo art. 42 da Lei nº 11.343/2006. A natureza (crack, cocaína e maconha) e a quantidade não portentosa das drogas não ensejam maior reprovação penal. Noutro giro, não há maiores informações sobre a personalidade e a conduta social do agente.

Já, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas no art. 59 do CP, verifico que: a culpabilidade é normal à espécie delitativa; o réu não ostenta condenações criminais anteriores transitadas em julgado, e a persecução penal em andamento não pode ser considerada para exasperar a pena-base (Súmula nº 444 do STJ); o motivo é inerente ao elemento subjetivo do delito; as circunstâncias e as consequências do crime são próprias do tipo penal, no aspecto objetivo, não justificando maior reprimenda; está-se diante de crime vago, não se cogitando de comportamento de vítima específica.

À vista dessas circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base no piso de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes nem agravantes. Entretanto, a fim de não desrespeitar o patamar estabelecido pelo preceito secundário do tipo penal, deixo de atenuar a pena anteriormente dosada (Súmula nº 231 do STJ), a qual remanesce inalterada.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição e/ou de aumento, ao que torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor mínimo unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, porquanto não há informações sobre a situação econômica do réu (arts. 49, § 1º, e 60, ambos do CP).

A Suprema Corte, por ocasião do julgamento do ARE 1.052.700/MG, ratificou o entendimento gizado de forma incidental pelo Plenário, no julgamento do HC 111.840/ES, de que é inconstitucional o art. 2º, §1º, da lei 8.072/1990. Donde a gravidade abstrata do tráfico de drogas, por si só, não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo – posição que está em consonância com as Súmulas nºs 718 e 719 do STF.

Mais recentemente, sufragando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, ao ensejo do julgamento do HC nº 596.603-SP, publicado em 22.09.2020, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São

Paulo em favor de João Faustino Neto, condenado como incurso no art. 33, "caput" e § 4º, da Lei nº 11.343/06, concedeu ordem individual e coletiva, constando da parte dispositiva:

1. Em relação ao paciente JOÃO FAUSTINO NETO, fixar o regime aberto como modo inicial de cumprimento da pena.
2. Em relação aos presos que se encontrem em situação igual (condenados, por delito de tráfico privilegiado, a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime fechado), conforme informação da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, determinar aos respectivos juízes das Varas de Execução Penal competentes e responsáveis pela execução das sanções dos internos que procedam à mudança do regime de pena para o aberto.
3. Em relação aos presos condenados, por delito de tráfico privilegiado, a penas menores que 4 anos de reclusão - salvo os casos do item anterior determinar que os respectivos juízes das Varas de Execução Penal competentes e responsáveis pela execução das sanções dos internos reavaliem, com a máxima urgência, a situação de cada um, de modo a verificar a possibilidade de mudança do regime inicial em face de eventual detração penal decorrente do período em que tenham permanecido presos cautelarmente.
4. Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena. (Negritei).

A Corte Superior de Justiça estabeleceu diretrizes a serem observadas pelos juízes e tribunais de todo o País, dentre as quais:

2.b. O condenado por crime de tráfico privilegiado, nos termos do art. 33. § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena inferior a 4 anos de reclusão, faz jus a cumprir a reprimenda em regime inicial aberto ou, excepcionalmente, em regime inicial semiaberto, desde que por motivação idônea, que não derive da mera natureza do crime, de sua gravidade abstrata ou da opinião pessoal do julgador (art. 33 c/c art. 59 do Código Penal e art. 42 da LAD)

2.c. O condenado por crime de tráfico privilegiado, nas condições e ressalvas da alínea anterior, faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme os critérios do art. 33 do Código Penal (e ante o afastamento, por ser inconstitucional, da vedação do art. 44 da Lei n. 11.343/2006, ex vi da Resolução nº 5 do Senado Federal, decorrente do julgamento do HC 97.256, pelo STF).

No mais, não descuro que a detração, instituto inerente à prolação da sentença condenatória para fins de estabelecimento de regime inicial, não deve ser confundida com o cômputo do tempo de segregação preventiva na progressão de regime, que compete ao juízo da execução. Assento, antes, que, como vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "com o advento da Lei 12.736/12, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado" (HC n. 443.419/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.06.2018).

Nessa ordem de ideias, fixo o regime semiaberto para início do resgate da pena corporal, em vista do quantum da reprimenda e das circunstâncias judiciais favoráveis (art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do CP). Eventuais pleitos de progressão de regime e detração penal devem ser formulados perante o juízo das execuções, competente para tanto, porque ausentes notícias sobre a real situação carcerária do acusado (art. 112, § 1º, da LEP). Nessa linha:

Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo (artigo 157, § 2º, inciso II e §2ºA, inciso I, do Código Penal). Insurgência da Defesa pleiteando a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento do aumento aplicado à pena em virtude do emprego da arma de

fogo e a aplicação de apenas um aumento na terceira fase da dosimetria, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, além da fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena corporal e a aplicação da detração penal. Impossibilidade da aplicação da absolvição pleiteada. Robusto conjunto probatório que impõe a manutenção da condenação do réu. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelas provas dos autos. (...). Regime fechado mantido ante a gravidade do crime praticado e a reincidência em crime patrimonial ostentada pelo réu. Pedido de detração que deve ser apreciado pelo juízo das execuções. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP, Apelação Criminal nº 0091137-83.2018.8.26.0050, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Osni Pereira, j. 06.05.2021). (Negritei).

Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, mercê da quantidade da sanção corporal imposta (arts. 44, I, e 77, caput, do CP, a contrario sensu).

Denego o apelo em liberdade. Há risco de reiteração delitiva, diante da dificuldade do acusado em aceitar a ordem legal estabelecida, de maneira que, caso solto, sua liberdade poderá colocar em xeque a tranquilidade social, porquanto terá os mesmos estímulos para delinquir. No preciso escólio de NORBERTO AVENA:

Entende-se justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir. (...)

Neste mesmo prisma, Guilherme de Souza Nucci, aduzindo, quanto à garantia da ordem pública, que se entende pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social. (Processo Penal – 11. ed. – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo; MÉTODO, 2019, p. 1.004).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para CONDENAR o réu THALES GOMES DOS SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de: (a) 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto; e (b) e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos).

Consoante fundamentação supra, mantenho a prisão preventiva do réu, denegando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Porém, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, visando à compatibilização da segregação cautelar ao regime imposto na sentença, DETERMINO A IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DO RÉU A ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO, o que faço em atenção ao entendimento do STJ, secundado pelo TJSP:

(...) 2 - Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, porém é necessário compatibilizar a prisão cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória. Precedentes.

(...)” (STJ, RHC: 140941 BA 2021/0003012-8, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJ 20.04.2021, DJe 28.04.2021);

(...) 4. A imposição do regime inicial semiaberto ao paciente, por si só, não lhe confere o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Expedição de ofício recomendatório com a determinação de expedição da guia de recolhimento provisória sendo assegurado ao paciente a permanência em regime prisional compatível com aquele estabelecido em sentença. (...) (TJSP, HC: 2253601-05.2020.8.26.0000, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 26.11.2020); e

(...) Manutenção da custódia preventiva que é compatível com a imposição do regime intermediário. Necessidade de mera adequação da situação carcerária do sentenciado ao regime ficado no édito condenatório. Ordem concedida em parte para determinar que o Juízo a quo adote, no prazo de 30 dias, as providências cabíveis para transferir o acusado ao regime intermediário, em observância à sumula vinculante nº

56 do C. STF. (TJSP, HC 2059949-86.2021.8.26.0000, 9ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sérgio Coelho, j. 30.04.2021).

Deixo de arbitrar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal (artigo 387, IV, do CPP), uma vez que se cuida de crime vago, que vulnera a saúde pública (bem jurídico difuso), e não houve requerimento explícito da acusação nesse tocante.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).

Declaro o perdimento dos bens e valores apreendidos em poder do agente em favor da União, o que faço com supedâneo no art. 63, §§ 1º e 2º, da Lei nº 11.343/2006.

Quanto aos entorpecentes, oficie-se à autoridade policial para que proceda à incineração.

Sobrevindo o trânsito em julgado: (a) lance-se o nome do réu no rol de culpados; (b) oficie-se ao TRE do domicílio eleitoral do acusado para fins de suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF) e para efeitos de inelegibilidade; (c) expeça-se a documentação necessária para a execução da pena; (d) oficie-se ao IIRGD para registro dos antecedentes criminais do acusado; e (e) remetam-se os autos à contadoria judicial para elaboração do cálculo da multa, intimando-se, em seguida, o acusado para recolhimento, em 10 dias, do valor pecuniário devido (art. 50 do CP).

Oportunamente, arquivem-se definitivamente os autos, promovendo-se as baixas nos registros.

Publique-se. Intimem-se.

Embu das Artes, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA